

1501257-68.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... para a delegacia ele confessou o tráfico e disse que lucrava cerca de R\$ 10.000,00 por mês; que ele já tinha duas passagens por tráfico; que nunca o tinha abordado, mas ele era conhecido por já ter passagem criminal; que salvo engano a esposa que morava lá com ele se chamava Magali; que não sabe se Magali foi à delegacia prestar depoimento; que foi Magali que falou que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

2ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501257-68.2021.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501257-68.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO FERRAZ DA ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISELA AGUIAR WANDERLEY

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de Eduardo Ferraz da Rocha, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Narra-se na denúncia que no dia 18 de novembro de 2021, às 9h20, na Rua Maracanã, n. 418, Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Atibaia, o acusado guardava, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 15 (quinze) porções de "crack" e 22 (vinte e duas) porções de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 96-97). Notificado (fls. 141), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 142/145). Recebida a denúncia (fls. 147-148), foi citado. Foram ouvidas duas testemunhas de acusação, quatro de defesa, interrogado o acusado e realizados debates orais.

O Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco nenhuma outra causa

extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

Para o exame da comprovação da materialidade e da autoria do fato descrito na denúncia, são relevantes, em especial, os seguintes elementos de informação e de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 1-10), boletim de ocorrência (fls. 11-13), auto de apreensão (fls. 14-15), laudos de exame pericial preliminar (fls. 16-17) e definitivo (fls. 91-93), bem como os depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

No ponto, passa-se a sumarizar os depoimentos colhidos.

A testemunha Marcela Abrantes de Aguiar, policial civil, relatou que foram fazer o cumprimento de um mandado de busca e apreensão com auxílio da guarda civil, na residência de Carol e Eduardo; que foram atendidos pela própria Carol e ao não encontraram nada de ilícito lá, nem o denunciado Eduardo; que ela informou que tinha se separado dele e que ele tinha se mudado de lá; que então começaram a questionar alguns populares que estavam na rua e foram informados de que na residência em frente havia também um Eduardo, mas que não era o Eduardo alvo das buscas, e que ele traficava junto com o Eduardo alvo; que foram então à residência dele, foram atendidos por ele, o qual negou o tráfico, mas ao ser questionada a esposa ela disse que ele traficava sim e disse que ele escondia pequenas porções de droga no terreno ao lado; que Hermes com os guardas foram a esse terreno e encontraram cocaína e crack em porções individuais prontas para venda; que na residência de Eduardo encontraram dinheiro em notas picadas no colchão e na gaveta; que ao ser levado para a delegacia ele confessou o tráfico e disse que lucrava cerca de R\$ 10.000,00 por mês; que ele já tinha duas passagens por tráfico; que nunca o tinha abordado, mas ele era conhecido por já ter passagem criminal; que salvo engano a esposa que morava lá com ele se chamava Magali; que não sabe se Magali foi à delegacia prestar depoimento; que foi Magali que falou que a droga escondida era de Eduardo.

A testemunha Hermes Jun Nakashima, delegado de polícia civil, relatou que de início havia uma investigação na delegacia de Atibaia dando conta de que uma mulher de nome Carolina e seu esposo de nome Eduardo estariam armazenando grande quantidade de drogas em sua residência, na rua Pacaembu, no bairro Jardim Imperial; que em diligências observaram que nesse endereço poderia de fato haver armazenamento de droga; que em razão disso solicitaram mandado de busca para cumprimento nesse imóvel; que foi deferido; que foram até lá e no dia só estava a Carolina, revistaram o imóvel e ela disse que o marido dela não estava e estaria em local desconhecido; que entendeu que ela não queria dizer onde o marido estava; que saíram na frente da residência perguntando onde Eduardo estava e se ele teria envolvimento com ilícito; que alguns populares que não quiseram se identificar e mencionaram que na residência em frente havia um Eduardo, que tinha envolvimento com atividade criminoso, juntamente com Eduardo, esposo de Carolina; que a residência ficava logo em frente e então procederam à busca; que a equipe estava em apoio, se adiantou e foi à diligência; que terminou as buscas com Caroline e logo em seguida foi acompanhar; que Eduardo já estava abordado e já tinha sido pressionado; que a esposa dele salvo engano Magali disse que de fato ele tinha envolvimento com o tráfico e mencionou que algumas porções de entorpecente dele ficariam em um terreno baldio, próximo à residência; que ele já era conhecido nos meios policiais; que diante da indicação da esposa dele rumaram para esse terreno, bem próximo à residência dele; que pelo indicativo dela, até onde estariam os entorpecentes; que foi até esse local e achou o entorpecente; que ele permaneceu negando o tráfico e disse que não tinha envolvimento com aquilo e a esposa inicialmente confirmou; que na residência dele encontraram dinheiro e ele disse que era fruto de obra, do trabalho dele; que Magali, se não se engana, ela se calou, porque percebeu a situação dela de ter entregado o marido dela, e não falou mais nada; que o alvo da investigação e do mandado de investigação era outro Eduardo, esposo da Caroline; que pela notícia de populares tinham então a fundada suspeita de que o acusado Eduardo estava envolvido e por isso prosseguiram com as diligências, e que então confirmaram a suspeita tanto que encontraram a droga; que eram uns trinta metros de distância entre as casas; que o terreno foi todo

vistoriado por cães depois de encontrarem a droga; que a droga estava em uma edícula, e dentro dessa edícula estavam as drogas; que depois só acharam a droga na edícula; que há dificuldade de colher declarações formais porque todo mundo tem medo de sofrer represália, então as pessoas atuam na verdade como informantes da polícia; que Magali não foi conduzida à delegacia; que ela falou pessoalmente consigo no momento em que chegou; que achou isso atípico, mas ela falou inclusive onde ele guardava o entorpecente, mas depois ela ficou um pouco receosa; que na casa de Caroline não encontraram nada; que, ao ser confrontado com Magali, disse que achava que ela estava na casa do Eduardo; que não se recorda bem da fisionomia, mas acredita ser essa pessoa sim; que inicialmente os guardas municipais que foram à casa do acusado Eduardo; que a droga não estava dentro da casa de Eduardo, mas sim em um terreno baldio onde há uma pequena edícula, bananeira, em estado aparente de abandono; que ficava a uns trinta metros da casa de Eduardo; que estava no fundo da edícula, sem porta, em estado de abandono realmente, e em cima da pia havia um copo com arroz e a droga; que o terreno era aberto e pode-se dizer que ele era acessível por terceiros; que primeiro encontraram o dinheiro, que acha que foi Eduardo que disse que poderia entrar na casa porque não encontrariam nada de ilícito.

A testemunha Luís Henrique Cometi Leme, guarda municipal, relatou que tinham um mandado a cumprir junto à polícia civil no Jardim Imperial, em determinada casa de pessoa de nome Eduardo; que foram informados de que Eduardo moraria na casa da frente, salvo engano com mesmo número, mas na casa à frente; que então adentraram na casa; que de pronto ele confessou a traficância e os levou aonde estava o dinheiro; que a esposa do acusado disse onde estava a droga, em um terreno ao lado; que acharam os entorpecentes e com isso o doutor tomou as medidas cabíveis; que inicialmente foram à casa de Caroline e Eduardo; que salvo engano só passaram para ele que estavam na casa errada e que Eduardo estava em outra casa; que bateram na porta, que estava encostada, sem trancar, então entraram; que os dois estavam no quarto, e eles estavam dormindo; que os dois se levantaram; que ele falou que já sabia o que estava acontecendo e disse que “perdeu” mesmo; que acharam droga no terreno ao lado da casa dele, onde a esposa falou que encontrariam o kit de drogas; que o terreno era mais ou menos a uns cinquenta metros, no máximo; que havia droga dentro de um copo com um pouco de cocaína; que o crack estava dentro de um maço de cigarro, perto da cocaína também; que depois de acharem a droga eles não falaram mais nada, não sabe se disseram para a polícia civil; que não sabe se Eduardo acusado que era o alvo da investigação, do mandado, isso quem sabe é a polícia civil; que Eduardo só apontou onde estaria o dinheiro advindo da traficância feita à noite e a esposa dele que apontou onde estavam as drogas; que a polícia civil já tinha essa informação de que as drogas estavam no terreno ao lado, mas não sabe se foi passada por ela ou por ele, mas eles obtiveram também naquele momento; que dias antes já haviam conduzido Eduardo pela prática de tráfico no mesmo local e o delegado decidiu ele cumprir o processo em liberdade; que não lembra do nome da esposa dele; que ela estava grávida e não sabe se a criança já nasceu; que não se lembra do nome Magali Lopes da Silva; que, ao ser confrontado com a testemunha Magali Lopes da Silva (em vídeo), não se recorda, mas acredita que não é a mulher que estava na casa com ele.

A informante Magali Lopes da Silva relatou que é ex-mulher de Eduardo; que não estava na casa dele; que estava na sua casa; que ficou sabendo que ele estava preso no dia seguinte, pois a mãe dele mandou mensagem; que vai à casa dele de quinze em quinze dias para deixar a filha; que tinha ido à casa dele no sábado anterior; que a mãe dele mandou mensagem dizendo que ele tinha sido preso, para contar para a sua filha; que acha que isso ocorreu às sete, oito da manhã; que não estava no local; que mora na rua Japão; que recebeu um áudio da mãe dele um dia após a prisão; que Eduardo tem uma esposa atual, é casado, com Aliandra; que não sabe como seu nome apareceu no processo.

A testemunha Aliandra Brandão Santos relatou que estava com Eduardo no dia da prisão, estavam em casa dormindo no momento da abordagem e foram pegos de surpresa; que até então eles invadiram a casa, averiguaram a casa com os cachorros e até então não foi encontrado nada; que, depois, colocaram o Eduardo para fora e um dos

policiais permaneceu dentro da casa consigo; que em seguida foram acompanhar a abordagem na outra casa, não acharam nada; que até então permaneceu na casa e os policiais continuaram na abordagem para fora; que não acharam nada de ilícito na casa; que a dona Rosa também acompanhou a abordagem; que não estava perto quando disseram da localização da droga; que ficou sabendo da prisão no dia seguinte, pelo papel do boletim de ocorrência; que foi à delegacia; que não conversou com o delegado ou os policiais; que já conhecia os policiais da rua mesmo e de uma abordagem que fizeram ao seu marido alguns dias antes; que, nessa abordagem, não agrediram o réu; que sua sogra não mora consigo, mas ela viu o momento em que as viaturas foram para lá, pois ela mora do outro lado da rua; que não sabe ao certo quando ela chegou; que os policiais invadiram, pediram para que levantassem; que eles procuraram na casa e não acharam nada; que acharam o dinheiro apenas, uma parte na gaveta do armário e outra parte próximo da sua estante; que o dinheiro era parte do trabalho de Eduardo, que é pedreiro, e outra parte era a pensão das suas crianças; que a pensão recebe de acordo de boca com o pai das crianças, R\$ 400,00, e ele paga todo dia 10 do mês; que eles levaram R\$ 1.410,00; que não gastou nada da pensão porque estava guardando para a festinha de um de seus filhos, que faz aniversário dia 19; que não sabe onde estavam as drogas, não chegou a vê-las. A testemunha Rosa Borges Ferraz relatou que mora na outra rua e quando viu a abordagem foi lá; que trabalha à noite e tinha acabado de chegar do serviço; que chegou lá, ele estava lá dentro com ele e os cachorros, depois tiraram ele para fora; que ficou perto dele, todo o tempo, não saiu; que não acharam nada com os cachorros e tudo; que nenhum policial conversou consigo; que só estavam seu filho, sua nora e ela, e não havia ninguém na rua, pois estava chovendo; que os acompanhou e eles não mostraram nada.

Por fim, o acusado Eduardo Ferraz da Rocha expôs que no dia dos fatos estava em sua casa deitado, dormindo com sua esposa, quando ouviu o barulho da porta, arrombando, e já acordou com os policiais, com a arma na cabeça, mandando levantar; que levantou sem saber o que estava acontecendo e começaram a fazer a busca; que depois o tiraram para fora e continuaram a abordagem; que ficaram dois policiais consigo e os demais saíram para a rua; que quando voltaram disseram que estava preso e já o levaram para a delegacia; que não falaram por que estava sendo preso, só veio a saber disso na audiência de custódia; que eles saíram no sentido à direita da casa, mas não viu para onde eles foram; que eles demoraram uns vinte minutos, meia hora, retornaram, e aí colocaram-no dentro da viatura; que não tem ideia de para onde eles foram; que eles falaram que a droga foi encontrada em um terreno baldio, mas ao que se recorda não há terreno baldio, não se lembra de nenhum terreno baldio; que só tem um parquinho, uma praça em frente à sua casa; que não se lembra de local como o descrito pelo delegado; que eles acharam o dinheiro; que há uns meses atrás já o tinham levado à delegacia por tráfico, disse sua versão e foi liberado; que esse policial Leme várias vezes o aborda em frente à sua casa; que não conhecia o delegado, Dr. Hermes; que a sua esposa Aliandra estava na casa e não conversou com os policiais; que sua mãe estava de pé no portão de casa e ficou ao seu lado; que não sabe por que o delegado teria dito que sua esposa falou a localização das drogas; que os policiais arrombaram a porta e até assustou, estava dormindo. Diante do acervo probatório acima sumariado, a despeito das substanciais razões apresentadas pelo Ministério Público em alegações finais pela condenação, constata-se que a absolvição por ausência de prova (CPP, art. 386, VII) se impõe, pois é consectário da ilicitude da entrada em domicílio (meio de obtenção de prova), a qual implica a ilicitude da subsequente apreensão das drogas e respectiva perícia, por ser prova derivada, à luz do art. 5º, LVI, da CR/1988 e do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

Registre-se, no ponto, que não há outras provas obtidas por fonte independente que possam, com base em nexos de causalidade diverso, dar amparo à comprovação do fato-crime, à luz do art. 157, § 1º, do CPP, e tampouco há no caso demonstração de hipótese de descoberta inevitável pelos trâmites típicos e de praxe da investigação, à luz do art. 157, § 2º, do CPP. O laudo pericial sobre as drogas apreendidas é o único meio de prova admitido na legislação processual penal para a comprovação do tráfico de drogas (CPP, art. 158), conforme orientação do Superior

Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no HC 492.906/MS, Quinta Turma, DJe 12/09/2019 e HC 497.242/CE, Sexta Turma, DJe 12/08/2019).

Com efeito, a leitura da denúncia, conjugada aos depoimentos dos agentes policiais e da autoridade policial coletados em audiência, sob o crivo do contraditório, revela que, na data dos fatos, a polícia civil estava em cumprimento de mandado de busca domiciliar em outro endereço (Rua Pacaembu, n. 429), para apuração de crime de mesma natureza, qual seja, tráfico de drogas, imputado a outra pessoa (homônimo Eduardo, casado com Caroline). Por ocasião da execução da diligência, populares não identificados teriam informado aos policiais sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo ora acusado, que mora em endereço diverso, embora próximo (Rua Pacaembu, n. 418). Assim, ato contínuo, sem mandado judicial e com base apenas na denúncia anônima (dado que os populares não se identificaram nem foram identificados neste processo), sem apurar a verossimilhança e a confiabilidade da referida notícia apócrifa recebida, a polícia ingressou de modo forçado no domicílio do acusado, surpreendendo-o ainda a dormir com a sua esposa, e, após depoimentos informais de ambos, coletados na referida oportunidade (após o ingresso forçado na casa), efetuou a apreensão das drogas em terreno baldio vizinho e do dinheiro na própria residência, de modo a dar início à presente persecução penal. Diante da dinâmica fática supra sintetizada, bem evidenciada pela instrução processual, não há como afastar a ilicitude do meio de obtenção de prova empregado, pois não havia fundadas razões para o ingresso no domicílio (conforme orientação jurisprudencial no sentido de que a denúncia anônima é insuficiente para justificar a busca domiciliar). Tendo em vista que todas as provas foram obtidas a partir de tal ingresso em domicílio, inclusive os depoimentos (“confissões”) informais de Eduardo e sua esposa coletadas pela autoridade policial e sua equipe de apoio, deve ser reconhecida a sua ilicitude por derivação.

Explica-se.

A entrada forçada em domicílio tem natureza excepcional e, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988 (CR/88), só se justifica em casos de (1) prestação de socorro, (2) desastre, (3) flagrante delito e (4) determinação judicial (neste último caso, durante o dia - CPP, art. 241). A partir de uma interpretação teleológica do referido dispositivo constitucional, é possível constatar que a quebra da inviolabilidade domiciliar só se dá, em regra, mediante determinação judicial prévia e durante o dia: trata-se de medida restritiva de direito fundamental submetida a reserva jurisdicional. Excepcionalmente, nas três situações de urgência elencadas no referido dispositivo normativo (prestação de socorro, desastre e flagrante delito), é possível a entrada forçada em domicílio independentemente de autorização judicial prévia, e em qualquer hora do dia. Nessa linha de raciocínio, a expedição de mandado judicial de busca domiciliar consiste em medida prévia à efetivação de prisão ou de apreensão de coisas e elementos de convicção no curso da persecução penal. Tal diligência depende, em suma, de fundadas razões da presença das pessoas/coisas a serem presas/apreendidas no interior da residência em que se visa a executar a medida. Tal é a inteligência do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP).

Assim, diante da aparência da natureza criminosa de determinado fato (*fumus commissi delicti*) e de indícios da existência de pessoas envolvidas ou de quaisquer elementos de convicção quanto a tal fato em determinada residência, autoriza-se a expedição de mandado de busca domiciliar no curso da persecução penal. Sem tais fundadas razões supra, obsta-se a expedição de mandado de busca exploratória, como instrumento de varredura geral, como consectário da proteção constitucional à privacidade e à inviolabilidade do domicílio (CR/88, art. 5º, X e XI).

No julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a orientação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. Assim, caso o agente policial verifique fundadas razões da ocorrência de flagrante delito em determinada residência, autoriza-se a imediata entrada forçada em

domicílio, a qualquer tempo, independentemente da prévia expedição de mandado judicial de busca, pois em tal situação há presunção de urgência para a repressão imediata da conduta criminosa atualmente em curso, o que justifica a postergação do controle jurisdicional da validade do ato, na linha das situações urgentes já previstas no art. 5º, XI, da CR/88. Sobre o afastamento de tal presunção de urgência nos casos de crimes de perigo abstrato permanentes e sem risco de perda/destruição da prova, cf. STJ, HC 598.051/SP, Sexta Turma, DJe 15.3.2021; HC 616.584/RS, Quinta Turma, DJe 6.4.2021.

Nessa ordem de ideias, vale notar que, desde o julgamento do RE 603.616/RO pelo Plenário do STF, evidenciou-se na jurisprudência que o standard probatório exigido para a expedição de mandado judicial de busca domiciliar (CPP, art. 240) e o standard probatório exigido para a entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente (CR/88, art. 5º, XI) é exatamente o mesmo: fundadas razões da ocorrência da infração penal e da existência de elementos de convicção quanto a ele no interior da residência.

Assim, tanto a validade da entrada policial forçada em domicílio diante de flagrante de crime permanente quanto a validade do mandado judicial de busca domiciliar são analisadas à luz do mesmo critério: com base em seus fundamentos (fatos de conhecimento anterior à medida), e não com base em seus resultados (fatos de conhecimento posterior à medida). Logo, se o policial promove a entrada policial forçada em domicílio a partir de fundadas razões quanto à situação de flagrância de crime permanente, a medida não será invalidada apenas em razão de ter tido resultado negativo (não obtenção de prova do crime). O mesmo raciocínio se aplica ao mandado judicial: a decisão que determina sua expedição será válida se estiver devidamente fundamentada em fundadas razões do ilícito, e não se o resultado do cumprimento do mandado for positivo.

Nesse rumo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) já firmou a orientação de que não pode a polícia avançar "imóvel adentro, em abusivo proceder, amparado em mera desconfiança" e fez constar a advertência de que a validade da busca domiciliar depende de seus fundamentos e não de seus resultados: "a validar diligências policiais em tais circunstâncias, a vedação de invasão de domicílio será reduzida a nada, porque é óbvio que a sua licitude não pode ficar na dependência do êxito ou não da diligência que os policiais arbitrariamente entenderam por bem empreender, como a aqui versada, com invasão da esfera da intimidade de alguém para, só então constatarem a ocorrência de um crime e assim prenderem o suspeito. Não é por cuidar a hipótese de crime permanente que estão legalizados todos os atos praticados pelos agentes públicos. Para se legitimar o flagrante em delitos dessa natureza é necessário que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime, e não mera desconfiança" (TJSP; Revisão Criminal 2000948-73.2021.8.26.0000; 1º Grupo de Direito Criminal; j. 09/08/2021).

Desse modo, à luz de tais premissas gerais, ao avançar para a casuística, verifica-se que, diante da tutela constitucional ao direito à privacidade e em especial à inviolabilidade domiciliar, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e consolidada no sentido de que a denúncia anônima (notícia apócrifa de crime), por si só, sem que sejam promovidas diligências preliminares mínimas para corroborar a sua verossimilhança e confiabilidade, não é fundamento suficiente para justificar o ingresso forçado em domicílio (não configura fundadas razões). Para subsidiar a deflagração da persecução penal formal e a execução de medida investigativa invasiva como a busca domiciliar (ou como a interceptação telefônica), a denúncia anônima deve ser objeto de averiguação de confiabilidade e verossimilhança, mediante diligências investigativas preliminares a serem encetadas pelas autoridades públicas.

Nesse sentido: STF, HC 106152/MS, j. 29/3/16; STF, RHC 117988, Rel. p/ Acórdão Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/12/2014; STF, HC 106664, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/08/2013; STJ, HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019; STJ, HC 442.363/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/08/2018; STJ, AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/03/2018; AgRg no REsp 1521711/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21/05/2015.

Uma premissa dessa sólida orientação jurisprudencial é a de que o anonimato inviabiliza a responsabilização pela informação falsa. Logo, a notícia apócrifa de crimes pode eventualmente ser instrumentalizada como meio de vingança entre cidadãos com desavenças das mais diversas espécies (por exemplo, de natureza familiar, empresarial ou política), ou mesmo como forma de abuso de poder pelas próprias autoridades públicas. Assim, ante a vedação ao anonimato (CR/88, art. 5º, IV), a inviolabilidade do domicílio (CR/88, art. 5º, XI) e a inviolabilidade da vida privada (CR/88, art. 5º, X), não se admite que a denúncia anônima seja por si só suficiente para a deflagração de persecução penal e a prática de medidas investigativas invasivas, submetidas inclusive à reserva jurisdicional. Trata-se de corolário do devido processo legal (CR/88, art. 5º, LIV) e do Estado de Direito, em que toda ação estatal privativa ou restritiva de direitos deve ser passível de controle (externo e interno). Tal controlabilidade é obstaculizada pela admissão de intervenções estatais restritivas de direitos com base em simples denúncias anônimas. Daí ser necessária verificação prévia, pelas autoridades públicas, quanto à confiabilidade e quanto à verossimilhança de tais denúncias antes de instaurar a respectiva investigação sobre os fatos narrados, para viabilizar o controle e evitar o abuso, seja sob a forma do excesso, seja sob a forma do desvio de poder.

Tais fundamentos, é interessante notar, transcendem a jurisprudência nacional. No direito comparado, notadamente na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, é também consolidado o entendimento de que medidas restritivas da privacidade individual (regidas pela Quarta Emenda à Constituição) não podem ser praticadas com base em denúncia anônima sem elementos para apuração de sua confiabilidade e credibilidade (cf. leading case: Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108, 1964).

Uma vez firmadas tais premissas, no caso ora em apreço, vale notar inicialmente que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial está suficientemente provado, pois (1) a policial Marcela não acompanhou a diligência, (2) o delegado de polícia Hermes só chegou ao local após a abordagem inicial, quando Eduardo e sua esposa já haviam sido abordados pelos guardas municipais, de modo que (3) apenas o guarda municipal Luís Henrique relatou a diligência em sua fase inicial, que inclui justamente o ingresso na residência. O seu relato, no ponto, foi no sentido de que bateram na porta, que estava encostada, sem trancar, então entraram; que os dois estavam no quarto, e eles estavam dormindo; que os dois se levantaram. Vale dizer, fica claro pelo relato do guarda municipal que não houve consentimento ao ingresso no domicílio. Tal relato é corroborado pelo depoimento da informante Aliandra Brandão (identificada como a esposa de Eduardo que estava no local – e não Magali Lopes, que consta dos documentos que integram o auto de prisão em flagrante), bem como pelo interrogatório de Eduardo: ambos disseram, assim como o guarda municipal Luís Henrique, que estavam dormindo em seu quarto quando foram surpreendidos pela repentina entrada da polícia na residência, ordenando que se levantassem. Por outro lado, verifica-se que o fundamento para tal entrada forçada em domicílio do acusado seria apenas a notícia, dada informalmente em via pública por populares que não quiseram se identificar, quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado em sua residência, situada ali perto, mas em endereço distinto do que constava do mandado judicial que então estava sendo cumprido pela polícia (fato reconhecido pela autoridade policial, delegado Hermes, e pela investigadora Marcela).

Embora seja totalmente compreensível o receio dos noticiantes com a sua própria identificação (ante a possível retaliação futura pelo alvo da diligência policial, tendo em vista a notória atuação de organizações criminosas nesta região), é forçoso reconhecer que, ante a não identificação dos noticiantes – nem mesmo pelos mecanismos institucionais existentes (Lei n. 9.807/99, Decretos Estaduais n. 44.214/1999 e n. 56.562/2010, Provimento n. 32/00-CGJ/TJSP) –, tal elemento de informação trazido sem fonte passível de verificação e de modo informal é portanto, equivalente a uma denúncia anônima.

Nesse rumo, vale notar que, com base na simples notícia de crime dada por transeuntes que não se identificaram, sem nenhuma corroboração por diligências

preliminares adicionais, nem mesmo o Poder Judiciário poderia expedir mandado judicial de busca domiciliar exclusivamente com base em tal fundamento, ante a ausência do requisito material respectivo (fundadas razões da infração penal – CPP, art. 240, § 1º) e à luz da jurisprudência supra. Logo, também não pode a polícia, sem mandado judicial, promover a busca domiciliar exclusivamente com base na notícia apócrifa recebida, a qual é reconhecidamente insuficiente para fundamentar medida invasiva como a busca domiciliar.

Assim, é imperativo consignar que tal modo de proceder – em resumo, ingresso forçado em domicílio pela polícia, no início da manhã, sem mandado judicial, com base em denúncia anônima sem averiguação preliminar, surpreendendo os moradores que ainda dormiam e submetendo-os a tomada informal de depoimento no mesmo ato – não é compatível nem com a Constituição (art. 5º, XI), nem com o Código de Processo Penal (art. 241) e, por conseguinte, não pode ser validado pelo Poder Judiciário.

Por fim, como fundamento em reforço ao que acima consta, vale acrescentar que, finda a diligência de busca e apreensão, auto circunstanciado deve ser subscrito por duas testemunhas presenciais, na forma do art. 243, § 7º, do CPP, ao passo que o art. 6º, III, do CPP determina a coleta de todas as provas que sirvam ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias.

No caso, a instrução processual culminou por revelar que a busca foi acompanhada por Aliandra Brandão e Rosa Ferraz, esposa e mãe do réu, respectivamente, mas nenhuma delas subscreveu auto circunstanciado da diligência, tampouco foram conduzidas à delegacia de polícia civil para prestar depoimento, embora fossem testemunhas da diligência e da subsequente prisão. Em tal cenário, essa irregularidade deu ensejo a um erro material na investigação, reproduzido na denúncia, qual seja, o de identificar como a testemunha da diligência a ex-esposa do acusado, Magali Lopes da Silva, que não foi reconhecida pelo guarda municipal Luís Leme e que foi reconhecida sem certeza quanto à sua fisionomia pelo delegado Hermes Nakashima. Vê-se, então, que a inobservância da formalidade legal acabou por dar ensejo à equivocada identificação da testemunha do ato, somente elucidada nesta audiência judicial por ocasião do contraditório.

As diligências policiais, então, foram efetuadas com violação à garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio (CR/88, art. 5º, XI, c/c CPP, art. 241) e com inobservância à legislação processual que rege os atos de investigação (CPP, art. 6º, III, c/c 243, § 7º), o que inviabiliza a condenação do acusado por meio do devido processo legal.

No ponto, é elucidativa a célebre e já quase centenária passagem do Justice Louis D. Brandeis, da Suprema Corte americana: “Em um governo de leis, a existência do Estado estará sob risco se este deixar de observar a lei escrupulosamente. O Estado [...], bem ou mal, orienta todo o povo pelo seu exemplo. O crime é contagioso. Se o Estado se torna um infrator da lei, ele convida à anarquia. Declarar que, na administração da justiça criminal, os fins justificam os meios – declarar que o Estado pode cometer crimes com o objetivo de assegurar a punição de um determinado criminoso – atrairia um terrível castigo” (Olmstead v. United States 277 US 485, 1928, tradução livre).

Portanto, embora as provas apontem sim a materialidade e a autoria da infração penal (notadamente confissão informal e apreensão da droga, conforme indicado pelo Ministério Público), tais provas são ilícitas por derivação e, conseqüentemente, inadmissíveis na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 e do art. 157, caput e § 1º do CPP. Logo, impõe-se a absolvição por ausência de provas lícitas aptas à comprovação da materialidade e autoria da infração penal descrita na denúncia.

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER o acusado da imputação contra si formulada neste feito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado.

Promova-se a destruição das amostras de droga eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Promova-se a restituição dos valores apreendidos ao acusado, na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).
Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Atibaia, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA